

刑法
No282

H22-7

(配点：3)

月 日

月 日

次の1から5までの各記述は、甲の占有する自転車を窃取した疑いで警察官の取調べを受けた被疑者の供述であるが、これらを判例の立場に従って検討した場合、その供述の内容が窃盗罪の成立を否定する主張となるものを2個選びなさい。

1. 「この自転車を自宅に持ち帰って分解し、売れそうな部品を中古部品屋に売却しようと思っていた。」
2. 「この自転車は、河原に捨ててあったので、通勤で使うために自宅に持ち帰ったものだ。」
3. 「駅に行く必要があったので、約30分ほどこの自転車に乗り、駅に着いたら駅前に乗り捨てるつもりだった。」
4. 「この自転車は、私が甲に貸してあったもので、甲が約束の期限を過ぎても返さないで、甲のいないすきに甲宅から自宅に持ち帰ったものだ。」
5. 「この自転車は、甲に対する嫌がらせのため自宅の物置に隠しておこうと持ち帰ったものだ。」

No282	不法領得の意思		正答率
H22-7	正解	2、5 (順不同)	84%

1 主張とならない

本記述では、自転車を自宅に持ち帰って分解し、売れそうな部品を中古部品屋に売却しようと思っていたとの主張が、不法領得の意思が欠けることを理由として、窃盗罪（235条）の成立を否定する主張となるかが問題となる。この点、判例は、窃盗罪の成立につき、不法領得の意思を必要とするとした上、その内容は、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として扱う意思（権利者排除意思）と、他人の物をその経済的用法に従い、利用又は処分する意思（利用処分意思）からなるとしている（大判大4.5.21）。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、不可罰な一時使用と可罰的な窃盗罪との区別、毀棄罪と窃盗罪との区別を適切に行う必要があることを挙げている。本記述において、被疑者は、甲の自転車を自宅に持ち帰ろうと思っていたのであるから、権利者排除意思、すなわち所有者又はその他の本権を有する者でなければ使用できないような態様において物を利用する意思が認められる。しかし、甲は、自転車を自宅に持ち帰って分解し、売れそうな部品を中古部品屋に売却しようと思っていたのであり、自転車に乗車するという典型的な利用目的を有していたわけではなかった。そこで、かかる甲に利用処分意思が認められるか、その内容が問題となる。この点、利用処分意思の内容については、財物から生ずる何らかの効用を享受する意思があればよいと解されている。本記述によれば、被疑者は、甲の自転車を分解して、売れそうな部品を売却することで利益を得ることを目指していた以上、利用処分意思を有していたと認められる。したがって、本記述は、不法領得の意思を否定する理由とはならず、窃盗罪の成立を否定する主張とならない。

2 主張となる

本記述では、自転車が河原に捨ててあったとの主張が、自転車が窃盗罪（235条）の客体である「他人の財物」に当たらないことを理由として、窃盗罪の成立を否定する主張となるかが問題となる。この点、窃盗罪とは、他人の所有する財物の占有を移転し、その占有を取得した場合に成立するものであるから、物であっても、誰の所有にも属さなければ、窃盗罪の客体とならない。よって、所有権を放棄された自転車などの無主物については、窃盗罪は成立しない。本記述によれば、自転車は河原に捨ててあったのだから、所有権は放棄されており、誰の所有の対象にもなっていないといえる。よって、自転車は、無主物に当たり、窃盗罪の客体である「他人の財物」には当たらない。したがって、本記述は、自転車が窃盗罪の客体である「他人の財物」に当たらないことを理由として、窃盗罪の成立を否定する主張となる。なお、判例も、被告人らがゴルフ場内にある人工池の底からゴルフボールを領得した事案において、「本件ゴルフボールは、無主物先占による権利の承継的な取得によるかは別として、いずれにせよゴルフ場側の所有に帰していたのであつて無主物ではなく、かつ、ゴルフ場の管理者においてこれを占有していたものというべきであるから、これが窃盗罪の客体になるとした原判断は、正当である」として、無主物は窃盗罪の客体に含まれないことを前提として判示している（最決昭62.4.10）。

3 主張とならない

本記述では、被疑者が約30分ほど自転車に乗り、駅に着いたら駅前に乗り捨てるつもりだったとの主張が、不法領得の意思が欠けることを理由として、窃盗罪（235条）の成立を否定する主張となるかが問題となる。この点、自転車の無断使用の事案において、判例は、無断使用後破壊し又は乗り捨てる意思がある場合には、不法領得の意思が認められ、窃盗罪が成立するとしている（大判大9.2.4）。本記述によれば、被疑者は、約30分ほどしか自転車に乗るつもりはなかったものの、自転車を駅に着いたら駅前に乗り捨てるつもりであったのだから、所有者又はその他の本権を

有する者でなければ使用できないような態様において物を利用する意思が認められる。よって、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として扱う意思（権利者排除意思）を有していたといえる。また、被疑者は、駅まで自転車に乗るつもりであったのだから、自転車をその本来の用法に従って利用する意思が認められ、物を利用処分する意思（利用処分意思）も有していたと認められる。したがって、本記述は、不法領得の意思を否定する理由とはならず、窃盗罪の成立を否定する主張とならない。

4 主張とならない

本記述では、自転車の持ち帰り行為は、甲に貸してあったものを甲が約束の期限を過ぎても返さないために持ち帰ったものであるとの主張が、窃盗罪（235条）の成立を否定する主張となるか、窃盗罪の構成要件該当性と違法性阻却の有無が問題となる。この点、貸金業を営んでいた被告人が、借主との間に買戻約款付自動車売買契約を結び、借主が買戻権を喪失した直後、借主の事実上の支配内にあった自動車を無断で引き揚げたという事案において、判例は、「被告人が自動車を引き揚げた時点においては、自動車は借主の事実上の支配内にあったことが明らかであるから、かりに被告人にその所有権があつたとしても、被告人の引揚行為は、刑法242条にいう他人の占有に属する物を窃取したものであるとして窃盗罪を構成するというべきであり、かつ、その行為は、社会通念上借主に受忍を求める限度を超えた違法なものであるというほかはない」としている（最決平元7.7、百選Ⅱ26事件）。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、①窃盗罪の保護法益は、事実上の所持そのものであるから、占有侵害があれば窃盗罪の構成要件該当性は肯定されること、②また、行為者の権利行使の側面は、違法性阻却を認めるべきか否かにおいて考慮すべきであるということ等を挙げている。本記述によれば、被疑者は、甲の占有する自転車を甲宅から持ち帰っている以上、窃盗罪の構成要件該当性が認められる。この点、自転車が被疑者の所有する物であったとしても、窃盗罪の成立を否定する理由とはならない。また、本記述によれば、被疑者は、甲のいないすきに甲宅に立ち入って占有を回復する手段をとっていることから、当該持ち帰り行為は、社会通念上借主に受忍を求める限度を超えた違法なものであるというほかなく、違法性が阻却されることはない。

したがって、本記述は、窃盗罪を構成しない適法な行為であることを理由として、窃盗罪の成立を否定する主張とならない。

5 主張となる

本記述では、自転車は、甲に対する嫌がらせのため自宅の物置に隠しておこうと持ち帰ったものであるとの主張が、不法領得の意思が欠けることを理由として、窃盗罪（235条）の成立を否定する主張となるかが問題となる。この点、判例は、窃盗罪の成立につき、不法領得の意思を必要とするとした上、その内容は、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として扱う意思（権利者排除意思）と、他人の物をその経済的用法に従い、利用又は処分する意思（利用処分意思）からなるとしている（大判大4.5.21）。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、不可罰な一時使用と可罰的な窃盗罪との区別、毀棄罪と窃盗罪との区別を適切に行う必要があることを挙げている。本記述によれば、被疑者は、甲の自転車を自宅に持ち帰ったのであるから、所有者又はその他の本権を有する者でなければ使用できないような態様において物を利用する意思が認められる。よって、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として扱う意思（権利者排除意思）を有していたといえる。しかし、被疑者は、自転車を甲に対する嫌がらせのために、自宅の物置に隠しておこうとして持ち帰っているため、利用処分意思を認めることはできない。したがって、本記述は、不法領得の意思が欠けることを理由として、窃盗罪の成立を否定する主張となる。